

1500921-84.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... essas conversas, é possível concluir que o réu praticava o tráfico ilícito de entorpecentes.

Ressalto que o simples fato de a droga não ter sido apreendida em grande quantidade, por si só, não afasta a tipificação do crime de tráfico. Aliás, atualmente, os traficantes vêm utilizando desse modo de agir (distribuição de pequenas porções entre vários entregadores), a fim de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

1ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500921-84.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500921-84.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2170064/2021 - DEL.POL.CLEMENTINA, 18668447 - DEL.POL.CLEMENTINA, 160/21/211 - DEL.POL.CLEMENTINA, 2170064 -

DEL.POL.CLEMENTINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX OLIVEIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

S E N T E N Ç A

Processo nº 1500921-84.2021.8.26.0603 (Controle nº 1295/2021)

VISTOS.

ALEX OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi preso em flagrante delito,

denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 23 de junho de 2021, por volta das 06h10min, na Rua Juarez Pereira de Souza, nº 401, Centro, cidade de Clementina, Comarca de Birigui, guardava 03 (três) porções de maconha, pesando um total de 27,54 gramas, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudos periciais de fls. 35/38 e 113/115.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado para apresentar defesa escrita (fl. 162), cuja peça foi juntada às fls. 156/161, sobrevindo o recebimento da denúncia em 09 de dezembro de 2021 (fls. 183/184). Na instrução, foram colhidos os depoimentos de 03 (três) testemunhas arroladas em comum, sobrevindo, ao final, o interrogatório do réu (fls. 253/254).

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia (fls. 266/271).

A defesa, por sua vez, pediu a absolvição do réu, alegando insuficiência de provas, uma vez que o depoimento do investigador foi contraditório e que os policiais não tinham autorização para adentrar na casa do acusado. Requereu o reconhecimento do princípio da insignificância, alegando que a droga encontrada era para uso próprio (fls. 274/278).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

De início, importante consignar que, ao contrário do que alega a defesa, os policiais civis tinham autorização para adentrar na residência, uma vez que foi concedida, por este juízo, autorização para busca e apreensão no endereço do acusado, bem como o acesso ao conteúdo constante nos aparelhos eletrônicos e telefônicos apreendidos.

Para tanto, basta simples consulta à decisão de fl. 22 do apenso 1501343-85.2021.8.26.0077, o que, ao que se percebe, não foi feito pela defesa.

No mérito, a ação penal é procedente.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido, temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); o boletim de ocorrência (fls. 23/27); a nota de culpa (fl. 13); o auto de exibição e apreensão (fls. 29/30); o relatório final (fls. 129/132); o laudo de constatação prévia (fls. 35/38); o laudo pericial (fls. 113/115); o relatório investigativo (fls. 42/52); o depósito judicial (fl. 101); os depoimentos das testemunhas; a confissão do réu apresentada na fase extrajudicial e sua posterior retratação em juízo.

Na delegacia, o réu confessou a prática de tráfico de drogas, assumindo a propriedade dos entorpecentes encontrados na sua casa. Confirmou que os celulares apreendidos são utilizados para o comércio de drogas (fl. 07).

A confissão livre e espontânea prestada no processo serve como importante elemento de convicção para evidenciar a autoria e amparar a condenação, quando encontrar sustentação nos demais elementos de convicção produzidos.

Em juízo, como sói de acontecer, alterou a sua versão e passou a negar a prática do tráfico, dizendo que os entorpecentes encontrados eram para uso próprio. Afirmou que, no horário dos fatos, estava trabalhando e seu vizinho Gilmar foi quem avisou sobre a presença dos policiais e por isso dirigiu-se até a Delegacia. Negou a propriedade do dinheiro encontrado. Os celulares apreendidos eram da sua esposa e enteada, e o que estava com visor quebrado era seu. Trabalhava como servente de pedreiro e também vendia roupas íntimas (fls. 253/254).

Como se viu, apesar de ter confessado a prática do tráfico na fase policial, o réu, em juízo, passou a negar a autoria do crime.

Diante das contradições apresentadas nos interrogatórios extrajudicial e judicial do réu, relacionadas a pontos de fundamental relevância para o deslinde da causa,

não há como se dar credibilidade à versão apresentada pelo réu na fase judicial, que restou isolada, se cotejada às demais provas coligidas sob o crivo do contraditório, que apresentaram grau de idoneidade bem mais elevado, como se verá doravante, não passando de mero expediente utilizado na tentativa de se furtar da responsabilização penal por conduta efetivamente praticada.

De outra parte, a prova oral produzida é robusta e só vem corroborando a confissão extrajudicial do acusado, caindo em descrédito a retratação judicial por ele oferecida. É que a simples retratação em juízo, sem ressonância nos autos, não invalida confissão feita perante a autoridade policial.

Com efeito, as testemunhas Bruno Vinícius Cordeiro Martins e André Luís da Silva, policiais civis, quando ouvidos na delegacia, relataram que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, dirigiram-se até a residência do réu que, avistando-os, fugiu, pulando o muro dos fundos da casa. Na casa, estava a esposa do réu, e no quarto do casal, encontraram duas porções de maconha, três celulares e um tablet, e na capa de um deles, a quantia de R\$ 100,00, em notas diversas. Localizaram, também, outra porção semelhante no sofá. A mulher do acusado confirmou que os entorpecentes e celulares pertenciam ao réu. O acusado foi encontrado e confirmou a propriedade da droga e dos celulares, e confessou que estava traficando entorpecentes na residência. Nos celulares, com autorização judicial, observou-se diversas conversas sobre a comercialização dos entorpecentes (fls. 03 e 05).

Em juízo, o policial Bruno acrescentou e esclareceu que, por conta de diversas denúncias, realizou ronda na casa e notou muita movimentação, razão pela qual a busca e apreensão foi autorizada judicialmente. Confirmou a elaboração do relatório informativo de fls. 42/52. Disse que a polícia militar foi informada e encontrou o réu perto da delegacia. (fls. 253/254).

Em juízo, o policial André, apesar de não se lembrar dos fatos, confirmou o depoimento prestado na fase policial (fls. 253/254).

Não obstante o policial André, em juízo, não ter se lembrado integralmente de detalhes da ocorrência, o policial Bruno judicializou suas declarações, confirmando a localização dos entorpecentes e as mensagens com teor de comércio de entorpecentes encontrados no celular do acusado.

Ademais, anoto que pequenas divergências entre seus depoimentos que não afetam, no substancial, a apuração da verdade, devem ser consideradas como fruto da capacidade de observação de cada um, tratando-se de lapso corriqueiro na evocação da memória descritiva, não maculando o fato principal. Aliás, como tem reconhecido a jurisprudência, pequenas contradições demonstram que elas disseram a verdade e não montaram seus depoimentos. Logo, como essas pequenas contradições não maculam o fato principal narrado na denúncia.

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Tais depoimentos somente não terá valor quando se evidenciar o interesse dos servidores na investigação penal, e quando suas declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

Importante salientar que não existe qualquer circunstância que justificasse o interesse dos policiais em prejudicar o acusado, ou em imputar falsamente a ele a prática de conduta definida como crime, sobretudo porque ele não apontou nada que justificasse essa circunstância.

A testemunha Maiara Farias dos Santos, amásia do acusado, na delegacia, silenciou a respeito dos fatos e, em juízo, confirmou que a droga encontrada pertencia a Alex, para uso próprio, e que ele não comercializa entorpecentes. Nada sabia sobre as mensagens encontradas no celular. Disse que, na época, eles vendiam várias mercadorias (xícara, tapetes, cuecas, panelas). Afirmou, também, que não tinha conhecimento de que o réu comprava chá. Contou que não foi apresentado o mandado de busca, e que falou aos policiais que a droga era para o acusado fumar e que não foi apreendida qualquer quantia em dinheiro (fls. 253/254).

No entanto, a versão judicial dessa testemunha, se cotejada com os demais elementos de prova, não pode merecer a mesma credibilidade, uma vez que ficou demonstrado que

a testemunha agiu com a intenção de afastar a responsabilidade do acusado, mas, por ser esposa do acusado, não responde pelo crime de falso testemunho. Não se pode olvidar, também, no caso, a intenção da testemunha de afastar a responsabilidade do acusado, vez que a incriminação deste poderia até colocar a testemunha como coautora, ou mesmo autora de outro crime (art. 28 da Lei de Drogas). Logo, seu depoimento não prevalece sobre os demais elementos de prova e é insuficiente para infirmar o restante da prova oral acima analisada.

No que se refere ao entorpecente, a perícia apontou que consiste realmente em "maconha" (exame químico-toxicológico de fls. 113/115). De outra parte, a quantidade de entorpecente apreendido, ou seja, 27,54 gramas de maconha, as circunstâncias da abordagem do réu (em cumprimento ao mandado de busca e apreensão); a forma de acondicionamento da droga (embaladas em porções), a apreensão de celulares e dinheiro e a confissão feita aos policiais e também na delegacia, evidenciam a traficância.

Ademais, o acusado não conseguiu comprovar a versão apresentada no interrogatório judicial, aliás, sequer arrolou como testemunha o vizinho "Gilmar" ou seu patrão, que poderiam confirmar que, no momento da apreensão da droga, estava trabalhando, providência essa que seria de fácil consecução, caso fosse verdadeira a narrativa apresentada em juízo.

Não se pode olvidar que, em um dos celulares apreendidos, com autorização judicial e do próprio réu, apurou-se a existência de mensagens referente ao tráfico, no seguinte teor:

À fl. 42, há uma conversa com o número 66 9645-2877, durante a madrugada, às 24:55, sobre venda e com pedido de brinde. À fl. 43, o número 18 99611-2517 deseja comprar R\$ 10,00 de chá do réu. Às fls. 45/47, verifica-se mais conversas sobre comercialização de entorpecentes, chamado de "branquinha", inclusive combinando como seria a entrega da encomenda. Destaco a conversa com "Menezes" fotografada à fl. 49, no qual é feita referência à comercialização de "3 pino" (sic). Por fim, às fls. 50/52, conforme conclusão contida no relatório investigativo, a conversa sobre a comercialização de entorpecentes foi feita com a esposa do acusado, confirmando que Alex vendia drogas.

Portanto, por essas conversas, é possível concluir que o réu praticava o tráfico ilícito de entorpecentes.

Ressalto que o simples fato de a droga não ter sido apreendida em grande quantidade, por si só, não afasta a tipificação do crime de tráfico. Aliás, atualmente, os traficantes vêm utilizando desse modo de agir (distribuição de pequenas porções entre vários entregadores), a fim de dificultar a apreensão da droga e a caracterização do crime de tráfico.

Nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado. No caso, o réu foi denunciado por guardar entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a venda a terceiros.

Assim, além da robusta prova acima analisada, há indícios mais que suficientes para a prolação de decreto condenatório. Aliás, neste ponto, tratando-se de delito, na maioria das vezes, praticado às escondidas, não se pode abrir mão dos indícios para o estabelecimento da verdade real. E a definição de indício vem estabelecida no próprio Código de Processo Penal, no artigo 239. Com isso, constata-se que o juiz formará a sua convicção na livre apreciação da prova, e, diante do nosso sistema processual, o indício é o fato provado que, por sua ligação íntima com o fato probando, autoriza a concluir algo sobre este, até porque os indícios estão inscritos no título da prova, e, assim, a autoria do delito, pelo sistema do livre convencimento, pode ser demonstrada, validamente, pela força probante dos indícios. Sendo assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local indicados na denúncia, o acusado guardava consigo 27,54 gramas de maconha, distribuídas em 03 (três) porções, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de entrega a consumo de terceiros.

A conduta do réu encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, exclua a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade. Neste ponto, embora o acusado tenha alegado que é usuário de drogas, tais alegações não restaram comprovadas, até porque a defesa não juntou quaisquer documentos, não requereu qualquer exame de dependência químico-toxicológico ou de insanidade mental.

Ressalto que, mesmo que se demonstrasse que o réu fosse usuário de drogas, isso, por si só, não lhe impediria de exercer a traficância. Muito pelo contrário, há grande afinidade entre uma e outra condutas. Se o réu é viciado há um bom tempo, isso facilita o ingresso no submundo do crime, principalmente no mercado de substâncias tóxicas.

Diante desse quadro, a condição de ser a agente usuário não exclui a possibilidade de ser condenado como traficante, porque são situações que não se excluem.

Descabida, portanto, a pretendida desclassificação do delito para o do artigo 28 da Lei de Drogas.

Reconheço, pois, a ocorrência do delito, e passo a aplicar a pena.

O acusado ostenta mau antecedente (fl. 280 - Processo nº 0017609-81.2008.8.26.0077), razão pela qual as circunstâncias do art. 59 do Código Penal não lhe são favoráveis, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (fls. 279 - Processo nº 0000377-49.2016.8.26.0603) e aumento a pena em mais 1/6 (um sexto), resultando em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, não vislumbro a existência de causas de aumento ou diminuição de pena. Neste ponto, não há como se aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, porque, entre os requisitos legais para tal benefício, o acusado deve ser primário e ostentar bons antecedentes, condições estas que o réu não ostenta.

Torno definitiva a pena em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Diante da gravidade da conduta, mesmo levando-se em conta a detração penal disposta na Lei nº 12.736/12 (art. 2º, que acrescentou o § 2º ao art. 387 do CPP), a pena deve ser cumprida no regime inicial fechado, obrigatoriamente, pois se trata de crime equiparado a hediondo, conforme estatuído no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.

Ademais, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária do acusado, isto é, se não registra outras condenações ou prisões processuais, nem quanto ao seu comportamento e conduta no cárcere, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à míngua de informações concretas.

O acusado deverá responder preso por este estão presentes os requisitos da custódia cautelar, como se verá doravante.

Fica fixado cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR ALEX OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90), e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no menor valor (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06), dando-a como incursa nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consigno que o acusado ficou preso cautelarmente desde 23/06/2021 até a presente data, período sobre o qual fica reconhecida a detração penal, para fins de cumprimento do restante da pena, nos termos do que dispõe o artigo 1º da Lei nº 12.736/12.

Deve, no entanto, a Serventia, ao expedir a Carta de Guia, atentar para se consignar a condenação total constante do dispositivo acima, com as observações consignadas no parágrafo anterior (detracção penal).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender incabível tal providência.

Não obstante o julgamento do Habeas Corpus n. 97.256, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se entendeu por inconstitucional a vedação à substituição por penas restritivas de direitos para o crime de tráfico, por afronta ao princípio da individualização da pena, até então não se trata de decisão proferida com efeito erga omnes.

Foi editada a Resolução nº 5/2012, do Senado Federal, que, nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, suspendeu a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, que vedava de forma abstrata (sem análise do caso concreto) a conversão em penas restritivas de direito, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo em decisão no Habeas Corpus já mencionado acima.

Com a mencionada Resolução, não se pode mais afirmar que o efeito do julgamento daquele habeas corpus não é para todos. Entretanto, a intenção do Supremo Tribunal Federal, ao decidir desta forma, e o Senado Federal, ao editar a resolução, foi somente deixar à prudente análise do magistrado do caso concreto se o réu tem ou não direito a ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, e não que essa substituição seja admitida em qualquer caso de tráfico de drogas, indistintamente. Pensar assim seria um contra-senso.

Confira, neste sentido, decisão proferida em Apelação Criminal que analisou sentença proferida por este juízo:

"... Inviável, nesse passo, a pretendida substituição carcerária por restritivas de direito, porque, embora o teor da recente Resolução nº. 5/2012 do Senado Federal, fundada na decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do Habeas Corpus, nº. 97.256/RS - mencionado nas razões recursais -, em controle difuso de constitucionalidade, in casu, permanece impossível, data vênua, a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, ou mesmo a concessão de sursis, pois o crime de tráfico de entorpecentes revela a gravidade peculiar que desestabiliza a vida em sociedade e fere de morte a saúde pública, pois enquanto fomenta, simultânea e irremediavelmente - até as pedras estão cansadas de saber -, a violência, a destruição de lares e das famílias e a prática de n crimes, sobretudo para o fim de viabilizá-lo, tanto assim que, por força de norma constitucional, é assemelhado aos delitos hediondos, cuja pena deve ser cumprida no regime prisional inicial fechado, determinação esta que se mostra incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou com a suspensão condicional da pena, de modo que não se consegue compreender ou avaliar, por mais que se esforce, qual seria a pena substitutiva ou as condições do sursis adequadas ao traficante, emergindo sintomático que - até o momento - jurista sério algum tenha ousado sugerir-las..." (TJ-SP, Apelação Criminal nº 0009435-15.2010.8.26.0077, 5ª Câmara Criminal, rel. Des. Juvenal Duarte, j. 19.04.2012).

Ainda no mesmo sentido, confira julgamento proferido em processo que tramitou por essa comarca de Birigui:

"Também não faz jus a apelante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados a tráfico de drogas é incompatível com a gravidade e as circunstâncias em que o crime é cometido, não havendo qualquer tipo de violação ao princípio da individualização da pena.

Este entendimento deve prevalecer, notadamente ao se considerar a vedação expressa trazida pelo artigo 44 da Lei de Drogas.

Com efeito, o benefício consistente na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tem por objetivo primordial o de possibilitar a ressocialização de indivíduos de baixa periculosidade, que praticaram delitos de

pequeno grau de lesividade social.

Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de pequeno, médio ou grande porte, não tem o perfil de iniciar o cumprimento de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor, as quais virão a repercutir a toda a coletividade. Ressalta-se que uma das exigências previstas no artigo 44, inciso III, do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é a de que os motivos e as circunstâncias indiquem como suficiente tal medida, para a repressão do agente da conduta delituosa.

Conforme já fundamentado, tal benefício não se coaduna com as graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causa, não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental, mas também ao corpo social (desestrutura familiar, estímulo à prática de outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).

Muito embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do "Habeas Corpus" nº 97256/RS, tenha expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no § 4º, do artigo 33, da Lei 11343/06, é de se ressaltar que tal decisão não possui o erga omnis.

E mesmo a resolução nº 5 do Senado Federal, de 15 de fevereiro de 2012, que suspendeu a eficácia da referida expressão, não acarreta direito subjetivo do agente que praticou o grave delito do tráfico de entorpecentes a tal conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Frise-se, ainda, que o artigo 44 da Lei de Drogas mantém tal vedação ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput. Considerando que o § 4º é tão somente uma causa de diminuição do delito previsto no caput - e não um crime autônomo -, é possível concluir que a vedação a ele também se aplica.

Neste aspecto, ensina Guilherme de Souza Nucci que "(...) o fato de haver sido prevista uma causa de diminuição de pena para o traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações criminosas, não afasta a tipificação da sua conduta como incursas no artigo 33, caput e § 1º, que são consideradas similares a infrações penais hediondas, como se pode observar pelas proibições enumeradas no artigo 44 da Lei 11343/06. Salienta-se, ademais, o cuidado legislativo em vedar a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, típica opção de política criminal para o tráfico ilícito de drogas. Não se pode criar uma nova infração penal, a partir da mera aplicação de causa de diminuição de pena. Por isso, o tráfico ilícito de drogas será sempre considerado equiparado a hediondo, ainda que comporte, por opção legislativa, pena mais branda, quando os requisitos do § 4º estiverem presentes" (in "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas", 5ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p.372). Desta forma, NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau" (Apelação Criminal nº 0002364-20.2014.8.26.0077. Rel. Toloza Neto).

Não bastassem esses argumentos, anoto ainda que o acusado é reincidente específico, ostenta maus antecedentes e a pena fixada ultrapassa quatro anos, o que afasta também a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O acusado deverá continuar a responder preso a este processo, eis que sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva, conforme decisão proferida às fls. 79/82, a cujos argumentos me reporto, como razão de decidir.

Ademais, continuam presentes os requisitos que recomendam a custódia cautelar do acusado, mormente porque praticou delito equiparado aos hediondos, lembrando que o acusado é reincidente específico no tráfico de drogas e ostenta péssimos antecedentes criminais, além do que, o réu, quando foi preso aqui, estava cumprindo livramento condicional por idêntico delito.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, com fundamento nos artigos 59 da Lei nº 11.343/06, c.c. o § 4º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, acrescentado pela Lei nº 11.464/07.

Por fim, em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de

Processo Penal, após 85 (oitenta e cinco) dias contados da publicação da sentença, tornem os autos conclusos para revisão da necessidade de manutenção ou não da decisão que manteve a prisão preventiva, mantendo-se os autos na fila "acompanhamento de prisão preventiva".

A incineração da droga já foi determinada realizada às fls. 79/82 e 165/166, nada mais havendo a ser decidido a respeito.

Como não restou provada a procedência lícita do dinheiro apreendido às fls. 29/30 (R\$ 100,00), não há como se deixar de reconhecer que é produto do tráfico de entorpecente, razão pela qual, com fundamento nos artigos 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e 63 da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento do dinheiro depositado à fl. 101.

Após o trânsito em julgado, comunique-se o "Senad" quanto ao perdimento supradeterminado (dinheiro), instruindo o ofício com cópias do auto de exibição e apreensão, da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Quanto aos objetos apreendidos (três celulares e um tablete), apesar de serem instrumentos do tráfico de drogas praticado pelo acusado, diante da sua natureza, entendo não ser caso de perda em favor do Senad, mas sim destruição imediata, a qual fica desde já determinada, expedindo-se o necessário e comunicando-se a Sala de Armas e Objetos Apreendidos.

Após o trânsito em julgado, oficie-se também à Delegacia de Polícia de origem, informando sobre o perdimento do dinheiro e destruição dos objetos, instruindo-se o ofício com as cópias mencionadas no parágrafo anterior.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Com o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 28 da Resolução nº 23.399/13 do TSE, instruindo o ofício com cópias da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Custas, na forma da lei.

P. R. I.

Birigui, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA